

1500998-71.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Agiam de comum acordo para o tráfico. Um se dizendo gerente do ponto de tráfico, outro seria o vendedor. Ambos estavam com drogas. E mais porções, grandes e pequenas, foram encontradas na casa de Peterson. Então, são traficantes de certa envergadura, longe da figura do pequeno traficante que a lei penal procura beneficiar.

Portanto, não é possível a diminuição de pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500998-71.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182806/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DA COSTA e outro

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 03 dias do mês de novembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e a Defensora Pública, Dra. Daniela Batalha Trettel(Def. Peterson), e dr. Olga Maria Vecchini Peaes (def. Eduardo). Apresentados os acusados EDUARDO DA COSTA E PETERSON DE LIMA GOMES, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Danilo Marco Lopes, Luciano Cardoso de Mello e Marcos Aparecido de Souza, e pela defesa do réu Peterson: Paulo César Minin.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista dos acusados com suas defensoras, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito aos acusados a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns (Danilo, Luciano e Marcos), e da defesa (Paulo César) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogados os réus (Eduardo e Peterson).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, PETERSON DE LIMA GOMES e EDUARDO DA COSTA como como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de julho de 2022, por volta de 14h20min, na Rua Maestro Luiz Dutra, altura do n. 109, - Jardim Noiva da Colina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, PETERSON DE LIMA GOMES, qualificado e indiciado às fls. 06-07, e EDUARDO DA COSTA, qualificado e indiciado às fls. 08-09, agindo em conluio e com identidade de desígnios delituosos, traziam consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 26 (vinte e seis) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 5,1g (cinco gramas e um decigrama) - item 1, laudo pericial de fls. 22-31, 57 (cinquenta e sete) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 11,1g (onze gramas e um decigrama) - item 6, laudo pericial de fls. 22-31, e 42 (quarenta e duas) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 5,7g (cinco gramas e sete decigramas) - item único, laudo pericial de fls. 32-34, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na mesma data e horário, na Rua Maestro Luiz Dutra, 109, - Jardim Noiva da Colina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, PETERSON DE LIMA GOMES, qualificado e indiciado às fls. 06-07, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, (um) tijolo grande e oito tijolos pequenos de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 847,3g (oitocentos e quarenta e sete gramas e três decigramas) - item 4, laudo pericial de fls. 22-31, 78 (setenta e oito) pequenas porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 147,2g (cento e quarenta e sete gramas e dois decigramas) - item 5, laudo pericial de fls. 22-31, 41 (quarenta e um) pinos contendo cocaína, com peso líquido de 14,3g (quatorze gramas e três decigramas) - item 3, laudo pericial de fls. 22-31, e 06 (seis) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 97,4g (noventa e sete gramas e quatro decigramas) - item 2 de fls. 22-31, laudo pericial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento notaram quando os denunciados deixaram o imóvel da Rua Maestro Luiz Dutra, n. 109, e adentraram em um carro com o adesivo do aplicativo "In Driver". Percebendo, ainda, comportamentos nervosos e suspeitos, abordaram o veículo. A condutora confirmou que tinha sido contratada pelos denunciados para uma "corrida". No veículo, nada de ilícito foi encontrado. Com PETERSON, os policiais apreenderam 26 porções de crack, R\$252,00 e um celular Motorola de cor azul. Em poder de EDUARDO, 57 porções de crack e R\$175,00. Depois, já apresentados na Delegacia de Polícia, em revista minuciosa, policiais civis encontraram sob as vestes íntimas de EDUARDO mais 42 porções de crack.

Aos policiais militares, ainda no local da abordagem, EDUARDO disse que tinha comprado a droga de PETERSON, uma parte para consumo próprio, outra para a venda. PETERSON assumiu ser gerente de um ponto de vendas e que ia com EDUARDO até o ponto, onde EDUARDO venderia o entorpecente, em troca de dinheiro e de uma pedra de crack. E que EDUARDO já tinha vendido certa quantidade na manhã daquele dia. Na sequência, os policiais, após indicação e autorização de PETERSON, foram até a residência deste (Rua Maestro Luiz Dutra, 109) e encontraram em um quarto 01 tijolo

grande e 08 pequenos de maconha, 78 porções de maconha, 41 pinos contendo cocaína, 06 porções de crack e uma balança de precisão.

Na Delegacia, PETERSON assumiu apenas as drogas encontradas em sua casa e disse que as guardava para "R.P." em troca de pagamento em dinheiro (fls. 06-07). EDUARDO ficou em silêncio (fls. 08-09).

Diante das circunstâncias, é certo que os denunciados, ao menos com relação aos entorpecentes que traziam consigo quando abordados no veículo "In Driver", agiam em conluio para a comercialização das drogas: cada um levava certa quantidade de porções que seriam comercializadas por EDUARDO em ponto de venda gerenciado e mediante pagamento de PETERSON. Com relação às drogas apreendidas no apartamento de PETERSON, considerando a quantidade, a diversidade, a apreensão de balança de precisão, a informação de que era responsável por um ponto de vendas, é certo que este as guardava e tinha em depósito para fins de comércio ilícito.

Auto de exibição e apreensão de fls. 16-17 e laudos periciais de fls. 22-31 e 32-34.

DANILO MARCO LOPES - PM - narrou que estava em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos saindo da residência e ao avistarem a viatura aparentaram nervosismo e na sequência entraram em um veículo com o adesivo do aplicativo In Driver. A motorista era uma mulher. Abordou o veículo. Os réus eram os ocupantes. Com Eduardo, cinquenta e sete porções de crack e dinheiro. Com Peterson, vinte e seis porções de crack e dinheiro. Eduardo disse que tinha comprado de Peterson, que ia usar um pouco e vender o resto. Peterson disse que era gerente de um ponto e que Eduardo era vendedor dele. Que Eduardo já tinha vendido droga de manhã e tinha ido até a casa dele (peterson) para buscar mais, e que ambos estavam indo de uber ao ponto de venda. Foram até a casa de Peterson. Ele mesmo abriu a casa, onde encontrou tijolo e pedações grandes e quantidade a granel de maconha, pinos de cocaína e R\$1.145,00. Embaixo da cama, encontrou um prato com seis pedras de crack e uma balança. Na delegacia, em revista minuciosa, dentro da cueca de Eduardo, mais 42 pedras de crack.

No mesmo sentido, LUCIANO CARDOSO DE MELLO - PM.

MARCOS APARECIDO DE SOUZA - Policial Civil - confirmou o encontro de drogas na revista minuciosa que fez em Eduardo, na Delegacia de Polícia.

Paulo Cesar, cunhado e amigo de Peterson, não presenciou os fatos. Narrou de forma positiva sobre as condutas social e profissional do réu.

PETERSON DE LIMA GOMES negou parcialmente os fatos. Disse que não tinha droga em seu poder. Que a chave de sua casa caiu no chão e os policiais a pegaram e abriram a casa. Em sua casa tinha droga. Recebia duzentos reais por semana para guardar as drogas. Os policiais não pediram autorização para abrir a sua casa. Pegou a droga para guardar porque estava passando por dificuldade financeira. Estava saindo com Eduardo para comprar itens que estavam faltando, já que estava mudando de casa e estava desmontando moveis com Eduardo.

EDUARDO DA COSTA disse que estava na casa de Peterson e um amigo de Peterson chegou e chamou lá fora. Essa pessoa lhe ofereceu drogas como pagamento por ajudar Peterson na mudança. Eram sete porções de crack. Nesse meio tempo, Peterson chamou um uber. Sabe que foi encontrada drogas na casa de Peterson. Na delegacia, também foram encontradas 40 porções de crack sob sua roupa. Na abordagem, os policiais encontraram 45 pedras. Depois, mais 40 sob sua cueca. Ia consumir e "ver o que ia fazer com o restante". Já vendeu droga para sustentar o vício de crack. Acredita que as duzentas porções de crack valessem uns duzentos reais.

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

Considerando a quantidade, diversidade e forma de embalagem das drogas, é certo que o réu a trazia consigo e guardava para fins de comércio.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à

venda. No ponto: " A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011). Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10) Considerando as circunstâncias da abordagem, a considerável quantidade e sua forma de embalagem é possível afirmar que a droga se destinava ao comércio ilegal.

DA PENA

Folha de antecedentes e certidões nos autos:- PETERSON DE LIMA GOMES - primário (fls. 59);- EDUARDO DA COSTA - primário (fls. 55-56).

Mas tinham sob sua guarda grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes. Agiam de comum acordo para o tráfico. Um se dizendo gerente do ponto de tráfico, outro seria o vendedor. Ambos estavam com drogas. E mais porções, grandes e pequenas, foram encontradas na casa de Peterson. Então, são traficantes de certa envergadura, longe da figura do pequeno traficante que a lei penal procura beneficiar.

Portanto, não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

As circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559).

E mais, cabe destacar que o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas instituiu o denominado tráfico privilegiado a prestigiar o princípio da individualização da pena, tendo por objetivo diferenciar as penas impostas ao traficante eventual e àquele que habitualmente se dedica à atividade criminosas.

E nessa seara, após longa discussão doutrinária e jurisprudencial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533/MS, reconheceu que a figura do "tráfico privilegiado de drogas", contida no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, não ostenta natureza hedionda, sendo, posteriormente, acompanhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao cancelar o enunciado de sua súmula nº 512.

O privilégio tem o condão de diminuir a pena de um a dois terços e demanda a presença de alguns requisitos cumulativos, quais sejam, a i) primariedade e ii) e bons antecedentes do agente, a iii) não dedicação a atividades criminosas e, por

fim, iv) não integração de organização criminosa. Na ausência de um destes elementos inviabiliza-se o reconhecimento da causa de diminuição. No tocante ao requisito da dedicação a atividades criminosas, tem-se que alguns fatores podem denotar habitualidade e envolvimento no crime, impedindo o reconhecimento da figura privilegiada.

Exemplo disso é a constatação de que o réu tinha grande quantidade e diversidade de drogas.

Ora, as circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559).

É o que permite o art. 42 da Lei 11.343/06.

Entendo não ser possível, também, pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado Peterson, manifestando-se sua

Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, PETERSON DE LIMA GOMES e EDUARDO DA COSTA como como incurso no artigo

33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal.

A Defensoria Pública atua em favor do acusado Peterson.

Segundo a denúncia (fls. 107/110), no dia 06 de julho de 2022, por volta de 14h20, na Rua Maestro Luiz Dutra, alturado n. 109, Jardim Noiva da Colina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, Peterson e Eduardo, agindo em conluio e com identidade de desígnios delituosos, traziam consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 26 (vinte e seis) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 5,1g (cinco gramas e um decigrama) - item 1, laudo pericial de fls. 22-31, 57 (cinquenta e sete) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 11,1g (onze gramas e um decigrama) - item 6, laudo pericial de fls. 22-31, e 42 (quarenta e duas) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 5,7g (cinco gramas e sete decigramas) - item único, laudo pericial de fls. 32-34, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda na inicial, consta que na mesma data e horário, na Rua Maestro Luiz Dutra, 109, Jardim Noiva da Colina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, Peterson guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 01 (um) tijolo grande e oito tijolos pequenos de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 847,3g (oitocentos e quarenta e sete gramas e trêsdecigramas) - item 4, laudo pericial de fls. 22-31, 78 (setenta e oito) pequenas porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido de 147,2g (cento e quarenta e sete gramas e dois decigramas) - item 5, laudo pericial de fls. 22-31, 41 (quarenta e um) pinos contendo cocaína, com peso líquido de 14,3g (quatorze gramas e três decigramas) - item 3, laudo pericial de fls. 22-31, e 06 (seis) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 97,4g (noventa e sete gramas e quatro decigramas) - item 2 de fls. 22-31, laudo pericial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a denúncia, policiais militares em patrulhamento notaram quando os denunciados deixaram o imóvel da Rua Maestro Luiz Dutra, n. 109, e adentraram em um carro com o adesivo do aplicativo "In Driver". Percebendo, ainda, comportamentos nervosos e suspeitos, abordaram o veículo. A condutora confirmou que tinha sido contratada pelos denunciados para uma "corrida". No veículo, nada de ilícito foi encontrado. Com PETERSON, os policiais apreenderam 26 porções de crack, R\$252,00 e um celular Motorola de cor azul. Em poder de EDUARDO, foram localizadas 57 porções de crack e R\$175,00. Depois, já apresentados na Delegacia de Polícia, em revista minuciosa, policiais civis encontraram sob as vestes íntimas de EDUARDO mais 42 porções de crack.

Aos policiais militares, ainda no local da abordagem, EDUARDO teria dito que tinha comprado a droga de PETERSON, uma parte para consumo próprio, outra para a venda. PETERSON assumiu ser gerente de um ponto de vendas e que ia com EDUARDO até o ponto, onde EDUARDO venderia o entorpecente, em troca de dinheiro e de uma pedra de crack. E que EDUARDO já tinha vendido certa quantidade na manhã daquele dia.

Na sequência, os policiais, segundo eles após indicação e autorização de PETERSON, foram até a sua residência (Rua Maestro Luiz Dutra, 109) e encontraram em um quarto 01 tijolo grande e 08 pequenos de maconha, 78 porções de maconha, 41 pinos contendo cocaína, 06 porções de crack e uma balança de precisão.

Na Delegacia, PETERSON assumiu apenas as drogas encontradas em sua casa e disse que as guardava para "R.P." em troca de pagamento em dinheiro (fls. 06-07).

O policial Danilo Marco Lopes, na delegacia (fls. 2-3), informou que: é policial militar e na data de hoje estava em patrulhamento de ações especiais na companhia do CB PM Cardoso a bordo da viatura E-10.106, quando na Rua Maestro Luiz Dutra, defronte ao numeral 109 avistaram dois indivíduos saindo da residência e ao avistarem a viatura aparentaram nervosismo e na sequência entraram em um veículo com o adesivo do aplicativo In Driver. Diante da ação dos indivíduos decidiram abordar o veículo, sendo que a poucos metros dali conseguiram parar o citado veículo. Conduzia o veículo uma mulher que se apresentou como sendo Carla Michele Mariano Bonato, RG: 34.783.215, e disse ser motorista de aplicativo e exibiu seu celular com a corrida em andamento, após busca no veículo nada de ilícito foi encontrado. Identificaram os dois indivíduos como sendo Eduardo da Costa e Peterson

De Lima Gomes, sendo que seu colega de farda procedeu a busca pessoal nos dois indivíduos, tendo encontrado com Eduardo cinquenta e sete porções de pedra amarelada aparentando ser crack e a quantia de cento e setenta e cinco reais, com Peterson seu colega de farda encontrou vinte e seis porções de pedra amarelada aparentando ser crack e a quantia de duzentos e cinquenta e dois reais e um celular Motorola de cor azul. Diante disso o depoente questionou Eduardo o que estava fazendo ali, tendo ele dito que tinha comprado a droga de Peterson e que iria usar um pouco e vender o resto. Questionado Peterson este disse que era gerente de um ponto de venda e que teria embalado a droga na casa onde os policiais o viram saindo e que estava acompanhando Eduardo até o ponto de venda, onde Eduardo venderia a droga. Peterson ainda disse que pagaria a Eduardo uma quantia em dinheiro e uma pequena pedra de crack e que Eduardo já tinha vendido uma quantidade de crack pela manhã. O depoente questionou se na residência havia mais drogas e Peterson admitiu a existência de mais entorpecentes, autorizando inclusive a entrada dos policiais na residência situada na Rua Maestro Luiz Dutra, 109, tendo aberto a porta do local com a chave dele. Relata que adentrou no local e em um quarto encontrou dentro de uma cômoda um tijolo grande e oito tijolos pequenos de erva aparentando ser maconha, setenta e oito pequenas porções de erva aparentando ser maconha, assim como quarenta e um pinos contendo pó branco aparentando ser cocaína, e em uma gaveta encontrou mil cento e quarenta e cinco reais em cédulas. No mesmo quarto debaixo da cama encontrou uma balança de precisão pequena suja de pó amarelado aparentando ser crack e seis pedras pequenas amareladas aparentando ser crack. Diante disso deram voz de prisão a Eduardo e Peterson, conduzindo-os até esta Delegacia. Não o conhecia, não houve resistência e não foi necessário o uso de algemas.

O policial Luciano Cardoso de Melo, na delegacia (fls. 4), informou o mesmo que seu companheiro de farda.

O policial civil Marcos Aparecido de Souza, na delegacia (fls. 5), informou que: é policial civil e na data de hoje estava cumprindo suas funções nesta Delegacia e quando foi realizar a revista de Eduardo da Costa, na presença do 2º Sgto. PM Lopes, para colocá-lo na cela desta unidade, no momento em que Eduardo tirou a cueca visualizou um pequeno saco contendo pedras amareladas aparentando ser crack pendurado no pênis de Eduardo. Pediu para Eduardo jogar no chão e então apresentou a Autoridade Policial. Após abrir o citado saco contabilizou quarenta e duas pequenas pedras.

Na delegacia, o investigado Peterson de Lima Gomes prestou o seguinte depoimento: que nunca foi preso ou processado. É amasiado e não tem filhos. É viciado em cocaína há seis anos. Parou de estudar no segundo ano do segundo grau porque não queria estudar. Trabalha como ajudante em obras. Quanto aos fatos, tem a dizer que estava de casa em um carro do In Driver. Poucos metros depois de o carro sair de sua casa foram abordados pela polícia. Alega que não tinha drogas consigo no momento da abordagem, apenas dinheiro e seu celular. Quando os policiais o questionaram se tinha drogas em sua casa, respondeu que sim e os autorizou a entrar no local entregando a chave da casa para eles. Afirma que as drogas encontradas em sua residência são de R.P. e que estava apenas guardando elas no local e que recebia quatrocentos reais a cada quinze dias por guardá-las. O dinheiro encontrado no armário era de sua propriedade. Questionado se foi agredido para confessar o crime, respondeu que não. Questionado se sofreu preconceito racial, religioso ou sexual, respondeu que não. Está arrependido.

Na delegacia, o investigado Eduardo da Costa exerceu seu direito constitucional de permanecer silente.

As fls. 55-56 e 59, juntadas certidões de objeto e pé que comprovam a primariedade de ambos os acusados.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelos laudos de fls. 22-31, 32-34 e 207-209. Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente ouvido o Policial Danilo Marco Lopes. Estavam em patrulhamento no bairro e viram dois indivíduos saindo de uma casa e entrando em um carro de

aplicativo. Eles demonstraram nervosismo, motivo pelo qual decidiram abordar. Eles olhavam para os policiais e apressaram os passos, como se quisessem fugir. Pararam o carro e, em revista, encontraram 57 porções de crack e R\$175,00 com Eduardo. Peterson tinha 26 porções de crack e R\$252,00. Eduardo falou que usava e vendia crack, que comprou de Eduardo. Peterson se disse gerente de um ponto de tráfico e iam até o local. Foram a sua casa buscar mais droga para vender, e que o dinheiro que tinham era resultado das vendas do período da manhã. Peterson falou que tinha mais drogas na casa, onde morava com a companheira, que não estava no local. Ali, teriam ingressado com a autorização de Peterson, que lhes entregou a chave. Encontraram um tijolo de maconha, 8 pedaços grandes da mesma droga e maconha a granel (cinquenta e poucos saquinhos). Também encontraram 41 pinos de cocaína e R\$1141,00. Embaixo da cama, havia um prato com 6 pedras de crack e uma balança de precisa. Na revista na delegacia, encontraram 41 porções de crack nas partes íntimas de Eduardo. Não conhecia os réus. Sobre a autorização para entrar na casa de Peterson, disse que ele concordou e que "acredita" que haja a autorização dele para ingresso no local colhida no BOPM. Negou que estivessem na frente da casa do réu Peterson parados, aguardando a sua saída.

b) Ouvido, em seguida, o policial Luciano Cardoso de Melo. Trouxe aos autos as mesmas informações do companheiro de farda.

c) Na sequência, ouvido o policial civil Marcos Aparecido de Souza. No dia dos fatos, encontrava-se na carceragem e, quando revistou Eduardo, encontrou uma porção de drogas em sua cueca. Eduardo ficou calado, nada disse sobre a droga.

d) Encerrando os testemunhos, ouvido Paulo Cesar Minin, testemunha de defesa de Peterson. O réu é irmão de sua esposa. Não viu os fatos. Peterson trabalhou com o depoente por 3 ou 4 anos. Ficaram parados por volta de 1 mês, por estarem sem serviço. Ele foi preso nesse período. Sabe que Peterson estava "apertado", pois a companheira estava grávida e a mãe dele, com quem residiam, mudou-se para morar com um companheiro - e Peterson teve que assumir sozinho as despesas da casa. Peterson é uma boa pessoa e trabalhador. Sempre foi obediente e não dava problemas.

e) Iniciados os interrogatórios, ouvido inicialmente o acusado Peterson de Lima Gomes. Eduardo foi na sua casa para ajuda-lo, pois estava se mudando. Estavam desmontando os móveis. Quando terminaram, saíram de casa e viu as viaturas do BAEP paradas. Foi abordado. Com ele, não havia nada. Ao ser algemado, viram a chave da casa em suas mãos. Perguntaram onde ele morava, indicou que era de onde estava saindo. Foram até lá com a sua chave e depois o levaram para o local, quando já havia policiais ali dentro. Os policiais pegaram a chave, perguntaram de onde era e, ao responder onde morava, os policiais foram andando e já entraram. Não pediram autorização para entrar e ele não autorizou. Tinha apenas 100 gramas de crack em casa. Pegou para guardar de uma pessoa chamada RP. Receberia 200 reais por semana. Estava guardando o dinheiro que ganhou para comprar coisas para o filho que está para nascer. Sua geladeira estava vazia, os policiais viram a sua situação, que estava em situação de necessidade. Estava indo com Eduardo comprar alguns itens da mudança (rodo e outras coisas desse tipo). A esposa estava na casa nova, limpando o local para a mudança. Quando estavam desmontando os móveis, RP foi na casa. Ele perguntou o que Eduardo estava fazendo no local, contou que estavam desmontando os móveis. Viu que RP falou de lado com Eduardo, acha que foi nesse momento que ele entregou a droga. Já usou cocaína. Conseguia ficar sem. Não tem nada contra os policiais ouvidos.

f) Por fim, ouvido Eduardo da Costa. Estava em casa ajudando Peterson a desmontar móveis. Peterson falou que um amigo queria falar com ele. Ele saiu e foi falar com essa pessoa, que uma quantidade de drogas para pagar pelo serviço que estava fazendo para Peterson. Eram 7 porções, mas não sabe a quantia de droga que havia em cada uma delas. Colocou 3 pedaços da droga no seu bolso e, antes de entrar no carro, colocou outras 3 porções na cintura. Peterson chamou o carro de aplicativo para irem ao mercado comprar umas coisas que faltavam. Eles acharam as drogas e o depoente disse que eram suas. Perguntaram de arma e "casa bomba". Não sabia de nada. Toda a droga era crack. Os policiais foram na casa de Peterson. Ficou na viatura. Soube na delegacia que encontraram 40 pedras de crack e, nas partes íntimas, outras 45 pedras. Ia usar uma parte da droga e a outra parte ainda não

sabia o que ia fazer. Por conta do vício, começou a fazer atividades paralelas, tais como cortar grama, e também já vendeu droga para sustentar o vício. É usuário de crack há 6 anos. Só conseguiu ficar sem usar quando está internado em clínica ou preso. Acredita que a droga que portava valia entre 200 e 250 reais.

PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA A PARTIR DE VIOLAÇÃO DA DOMICÍLIO Faz-se necessário frisar que a apreensão das substâncias entorpecentes que comprovaram parte da materialidade delitiva foi realizada no domicílio do acusado Peterson sem justa causa e sem mandado judicial que autorizasse a entrada no local. Isso porque a versão de que os policiais teriam sido convidados pelo réu para ingressar no local não é crível e não foi comprovada nos autos. Da mesma forma, o réu e foi claro: não autorizou o ingresso na casa.

Conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, é ônus do Estado comprovar que houve autorização dos moradores para ingresso no domicílio ou que havia justa causa para acesso à residência dos acusados sem ordem judicial.

No caso em tela, não só a justa causa não foi comprovada, como a narrativa dos policiais se mostrou inverídica.

Desse modo, o ingresso na residência deu-se em desconformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal (que dispõe sobre a inviolabilidade do domicílio).

De acordo com o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a busca domiciliar realizada sem a prévia expedição de mandado de busca e apreensão somente é legítima e não viola o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, quando presentes “fundadas razões” que a legitimem (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). De fato, segundo a tese fixada em sede de repercussão geral, tornando sua observância obrigatória pelos demais tribunais (CPC, art. 927, III, c. c/ art. 3º do CPP):

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Cumprе ressaltar que a possibilidade de ingresso em residência alheia, sem a expedição de um prévio mandado de busca e apreensão, nas hipóteses de flagrante, é situação que deve ser interpretada restritivamente, sob pena de se tornar inócua o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, para contenção do poder estatal e efetiva preservação da referida garantia, deve-se compreender que a invasão domiciliar, nas hipóteses de flagrante delito, somente está permitida quando se esteja diante de flagrante próprio, ou seja, quando a pessoa seja surpreendida enquanto está cometendo o crime, ou quando acaba de cometê-lo (CPP, art. 302, I e II).

As hipóteses de flagrante impróprio e presumido (CPP, art. 302, III e IV) não devem habilitar o ingresso na residência alheia, eis que se tratam de construções legislativa:

“Diante desse conjunto de disposições, fica claro que o ingresso no domicílio para obtenção de provas materiais, salvo o consentimento do morador, somente pode ocorrer na situação de flagrante ou mediante mandado judicial; no primeiro caso deve-se ter presente que a exceção constitucional apenas pode ser aplicada aos casos de flagrante próprio, não se estendendo às hipóteses previstas pelos incisos III e IV, do art. 302 do CPP, pois do contrário estar-se-ia admitindo que o legislador ordinário restringisse o alcance da garantia “(GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 121).

Insta consignar que o tráfico de drogas não possui vítima concreta, a sua prática lesiona a “saúde pública”. Dessa forma, ainda que se argumente que o crime de

tráfico de drogas é permanente, de modo que sua consumação resta protraída enquanto não cessada a prática criminosa, não será permitido o ingresso na residência do acusado com base no artigo 303 do Código de Processo Penal ("Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência"), pois tal dispositivo também deve ser interpretado à luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse contexto, é inequívoco que a situação de flagrante delito foi equiparada às hipóteses de desastre ou para prestação de socorro. Assim, o ingresso em domicílio alheio, sem a prévia expedição de mandado de busca e apreensão, só poderá ocorrer quando se pretender a proteção de um bem jurídico capaz de mitigar o alcance da garantia constitucional em tela. Exige-se, portanto, que o ingresso seja para salvar a vítima de um delito ou, ainda, a vítima de um desastre.

Percebe-se que o ingresso na residência de um cidadão, sem a prévia expedição de mandado de busca e apreensão, deve ser encarada como situação excepcionalíssima. No presente caso, embora as autoridades policiais aleguem que houve autorização do réu para ingresso em sua residência, não foi juntada aos autos prova da referida autorização. Conforme determina o Superior Tribunal de Justiça, é ônus do Estado comprovar que a autorização ocorreu, por via documental ou gravação de vídeo. Tais provas não constam dos autos, motivo pelo qual infere-se que o ingresso na residência se deu ilicitamente.

Destarte, com relação ao delito de tráfico de entorpecentes relacionado às drogas apreendidas na residência de Peterson, o laudo de constatação, não obstante ateste a materialidade do delito, é oriundo de uma ilicitude (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157) e, por isso, é imprestável para a formação do convencimento judicial. Da mesma forma, os depoimentos colhidos em juízo, naquilo que narram a descoberta das drogas, não podem ser considerados, posto que decorrem de invasão de domicílio e devem ser igualmente desentranhados (CPP, art. 157, caput). O mesmo se aplica à apreensão da munição.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Segundo Peterson, as únicas drogas que lhe pertenciam eram as que estavam em sua casa. Sendo a apreensão dessas drogas ilícita, não restam outras drogas que permitam a condenação do réu.

E não se diga que o relato dos policiais, segundo o qual havia drogas com Peterson no carro. Temos nos autos apenas as versões contrapostas do réu e dos policiais, e nenhum dos testemunhos tem maior peso ou relevância. A acusação, por sua vez, não trouxe aos autos outras provas que permitissem elucidar qual a versão verdadeira. Eventual sentença de condenação embasada nas declarações dos policiais seria fundada em elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal da acusada. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a

fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior. Da mesma forma, o réu é primário e a quantidade de drogas não é exacerbada. Tais circunstâncias, portanto, recomendam a pena-base no patamar mínimo.

b) Segunda-fase: atenuantes

A atenuante da confissão deve ser considerada (art. 65, III, d, CP), ainda que não altere a pena.

c) Aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD. Ora, estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo, sendo certo que, conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

Ainda, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o afastamento do privilégio com base apenas na quantidade ou na qualidade da droga apreendida:

Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas. (STJ. 5ª Turma. REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 29/03/2022. Informativo 731)

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, reconhecido o privilégio, de rigor a fixação do regime inicial aberto.

Ainda que não aplicado o redutor do art. 33, §4º, da LD, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO (DETRAÇÃO E ART. 387, § 2º, DO CPP)

Além disso, considerando que o réu respondeu preso ao processo, impõe-se que o tempo de prisão provisória seja declarado como tempo de pena já cumprida, efetuando-se, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração; é o que se extrai do referido dispositivo, assim como da Exposição de Motivos da Lei n. 12.736/2012 e da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Ademais, reconhecido o privilégio, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o Senado Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da CF, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A Resolução por conta do julgamento do Habeas Corpus 97.256/RS, em setembro de 2010, ocasião em que o STF, por seis votos a quatro, o STF decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Lei n. 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. Ainda que se discorde da conclusão alcançada pelo STF, o fato é que, com a edição da mencionada Resolução, pelo Senado Federal, restou afastado o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que suspensa a execução da lei, dotando a decisão do STF, tomada em sede de controle incidental, de efeitos erga omnes. Possível, pois, a aplicação de penas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do CP: a) a pena, ao final aplicada, não será superior a 4 anos; b) o crime

não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) o réu não é reincidente em crime doloso; d) a medida mostra-se suficiente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2) Dada a palavra à nobre defensora do acusado Eduardo, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, MM Juíza, segundo denúncia do Ministério Público, o réu encontra-se incurso nas sanções do crime prescrito no art. 33 da lei nº 11.343/06 c/c art. 29 do CP, posto que na data de 06/07/2022, foi preso em flagrante nesta Comarca, precisamente na Rua Maestro Luiz Dutra, altura do número 109, sob acusação de trazer consigo substâncias entorpecentes, sendo 11,1 g de Crack (57 porções), além de ser apreendido com a quantia de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco Reais). Ainda, após revista pessoal para recolhimento em carceragem, foi encontrado em sua posse mais 42 porções da mesma substância ilícita. Instruído o feito, o Ministério Público se manifestou pela procedência da exordial acusatória.

Diante da confissão livre e espontânea do réu, com efeito, a atitude do acusado exonera a defesa de se manifestar com profundidade sobre o mérito. No entanto, entende ser imprescindível algumas considerações acerca dos fatos e da pena a ser aplicada.

Primeiramente, demonstrando seu interesse em colaborar com a justiça configura evidente atenuante da reprimenda a ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

O laudo pericial acostado às fls. 32-34 revela que a quantidade de droga apreendida é ínfima (total de 16,8g) se considerarmos o tipo penal imputado. Assim, não se mostra razoável conferir ao réu o mesmo tratamento dispensado a um verdadeiro traficante de drogas, mormente em uma realidade social em que apreensões de dezenas ou centenas de quilos de entorpecentes ocorrem quase que diariamente no país.

Conforme o interrogatório judicial e a certidão de antecedentes acostada às fls. 55-58, o acusado é tecnicamente primário, sendo vedado a utilização de ações penais em curso para agravar a pena base, segundo a Súmula 444, STJ.

De mais a mais, o dolo é normal a espécie delitativa, e as consequências do crime não ultrapassam aquelas inerentes à gravidade comum do tipo penal, inexistindo, portanto, qualquer circunstância específica que sirva de fundamento para elevação da pena base.

Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante previstas no artigo 65, inciso III, alínea d do Código Penal.

Derradeiramente, na terceira fase, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado. Conforme dito alhures, o denunciado é tecnicamente primário e não há qualquer indício de que integre organização criminosa.

Nesse sentido, vale ressaltar a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo

Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em